

1500876-41.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcello Ovidio Lopes Guimarães

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL DOS SANTOS SILVA DE SOUSA

Aos 23/02/22, às 13 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19, apresentaram-se o MM. Juiz de Direito Marcello ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500876-41.2021.8.26.0228 - lauda

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500876-41.2021.8.26.0228

Controle nº 52/21

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL DOS SANTOS SILVA DE SOUSA

Aos 23/02/22, às 13 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19, apresentaram-se o MM. Juiz de Direito Marcello Ovidio Lopes Guimarães, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, certificou o comparecimento da Promotora de Justiça Angélica Luíza Rossi da Costa, o réu RAFAEL DOS SANTOS SILVA DE SOUSA e a sua defensora, Dra. Virgínia S. R. Caldas Catelan, Defensora Pública. Iniciados os trabalhos, na presente audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia. O réu foi interrogado. Pelo MM. Juiz foi dito que declarava encerrada a instrução, deliberando o início dos debates da causa. Pela acusação foi alegado em

síntese: Trata-se de ação penal movida contra RAFAEL DOS SANTOS SILVA DE SOUSA pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, uma vez que no dia 08 de janeiro de 2021, por volta das 22 horas e 05 minutos, na Rua Quaresma Delgado, na altura do nº 369, São Rafael, nesta cidade e comarca da Capital/SP, trazia consigo, para entrega e comercialização a terceiros pessoas, drogas, consistentes em 5,3g (cinco gramas e três decigramas) de cocaína, divididos em 77 (setenta e sete) invólucros plásticos, 12,4g (doze gramas e quatro decigramas) de Tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecido como maconha, divididos em 18 (dezoito) invólucros plásticos, 46,2g (quarenta e seis gramas e dois decigramas) de cocaína, divididos em 74 (setenta e quatro) invólucros plásticos, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 12/13, laudo de constatação a fls. 22/26 e exame químico-toxicológico de fls. 149/151. A denúncia foi recebida, o acusado foi citado e apresentou sua resposta à acusação. Foram então ouvidas as testemunhas de acusação e, ao final, o acusado foi interrogado. É o relatório do necessário. 2. O feito encontra-se formalmente em ordem, não havendo nulidades ou irregularidades a sanar. O acusado foi devidamente processado, com o respeito às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5.º, LV, da Constituição). No que diz respeito ao mérito da imputação, considerando os elementos de informação constantes do inquérito policial – iniciado por auto de prisão em flagrante delito – e as provas produzidas no curso da instrução processual penal, conclui-se que a pretensão punitiva deve ser julgada procedente. A materialidade do delito ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 5, boletim de ocorrência de fls. 6/8, auto de exibição e apreensão a fls. 12/13, laudo de constatação a fls. 22/26 e exame químico-toxicológico de fls. 149/151. A autoria, igualmente, ficou demonstrada pelos elementos dos autos, principalmente pelas provas orais colhidas em Juízo. A testemunha Lucas (policial) disse que a equipe estava em patrulhamento quando avistou o acusado com outro indivíduo que, ao avistarem a equipe, correram. Disse que, em abordagem, localizaram com o réu uma bolsa com os entorpecentes, em porções individualizadas, além de dinheiro. Disse que o réu confessou informalmente o tráfico. Não conhecia o acusado anteriormente. Não visualizou a efetiva venda de entorpecentes, mas como o acusado saiu correndo quando avistou a viatura, optaram pela abordagem. A bolsa com os entorpecentes não chegou a ser dispensada e foi apreendida na posse do acusado. Disse que o dinheiro estava na posse do acusado e não se recorda do valor. A testemunha Jessan (policial) não se recorda da ocorrência. Disse que o local é um ponto de tráfico extremamente movimentado. O acusado RAFAEL negou os fatos. Disse que não estava com drogas. Disse que a polícia achou os entorpecentes no chão e que foi uma terceira pessoa que dispensou os entorpecentes. Não conhece essa pessoa. Não conhecia os policiais anteriormente. Nunca foi processado anteriormente. Trabalha de ajudante de pedreiro. A despeito da negativa do acusado, como se percebe, da prova oral colhida em Juízo – corroborada pelos elementos já angariados em solo policial – não restam dúvidas quanto à prática do crime de tráfico perpetrado pelo acusado, confirmando-se as imputações descritas de forma minuciosa na peça acusatória. Não há porque duvidar da palavra do agente, que é funcionário público no exercício de suas funções, ouvido em Juízo como testemunha e sob o dever de dizer a verdade, sem qualquer interesse em prejudicar terceiros. Não é demais lembrar que os depoimentos de agentes de segurança pública são tão válidos e importantes quanto os de quaisquer outras pessoas, se a eles não se contrapõem fatos e provas que desmereçam sua credibilidade. Por fim, consigno que a quantidade de porções apreendidas, a forma como estavam acondicionados, bem como as demais circunstâncias da prisão em flagrante, indicam, com segurança, que o acusado se encontrava na prática do narcotráfico quando abordado, e que o entorpecente não se destinava ao consumo do seu portador (Lei 11.343/06, art. 28, §2º), mas sim ao comércio ilícito. Assim, presentes provas suficientes da autoria e materialidade, a condenação é medida que se impõe, nos exatos termos da denúncia. No que diz respeito à dosimetria da pena, atendendo às diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal, c.c. o artigo 42 da Lei de Drogas, consigno a variedade e quantidade apreendida (mais de cento e setenta porções de crack, cocaína e maconha), a ensejar a elevação da pena-base. Na

segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, a despeito da primariedade do acusado, de rigor seja afastado o privilégio previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, vez que o acusado trazia consigo grande quantidade de entorpecentes de alta nocividade, evidenciando que este não se trata de episódio isolado e mantém íntima relação com o narcotráfico. Por fim, considerando a gravidade em concreto da conduta do acusado, de rigor a fixação do regime inicial fechado. 3. Ante o exposto, o Ministério Público requer seja julgada PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de condenar o autor dos fatos nos exatos termos da denúncia. Pela defesa foi alegado, em síntese: Imperioso reconhecer, na espécie, que, ao cabo da instrução processual, o respeitável Órgão Acusatório não se desincumbiu de seu ônus probatório, em virtude do que a absolvição do acusado RAFAEL é medida de rigor. Em juízo, negou estar na posse das drogas descritas na inicial. Disse ser usuário de drogas e que o indivíduo que estava com a bolsa contendo drogas correu. Nunca foi processado anteriormente. É ajudante de pedreiro. Os policiais, por sua vez, não permaneceram em campana, bem como não visualizaram ato de compra e venda. A presumida inocência do acusado não foi infirmada pelo acervo probatório carreado ao caderno processual, resumida ao relato de apenas um dos policiais que participaram da ocorrência. O policial Jesson afirmou nada se recordar acerca destes fatos. O policial Lucas, por sua vez, em sede inquisitorial afirma terem visto 3 indivíduos, sendo que 2 teriam corrido, permanecendo apenas o acusado. Em juízo, muda a versão e diz que estava no local apenas o acusado e mais um indivíduo. Não disse quais as drogas apreendidas e nem se recordou da quantidade de dinheiro apreendida. Ao ser indagado, também disse não se recordar de como era a suposta bolsa apreendida. Os policiais não visualizaram ato de compra e venda e não realizaram campana no local. Resta pouco crível que em local conhecido como ponto de tráfico, o acusado estaria apenas com mais um indivíduo no local. O acusado não foi encontrado com celular ou anotações. Sequer foi apontada a existência de outras pessoas no local. Nenhuma testemunha estranha aos quadros da polícia foi ouvida nos autos. A alegada confissão informal não se fez refletir nos interrogatórios prestados tanto em sede inquisitorial quanto em juízo. É, no mínimo, irracional achar que o direito ao silêncio pode ser solapado por temerárias e inidôneas confissões informais, supostamente feitas a agentes policiais que, por certo, tenderão a atestar a lisura da prisão em flagrante que efetuaram. Assim, a alegação de confissão informal tem de ser cabalmente ignorada, POIS É FIGURA JURÍDICA ABERRANTE, QUE DESTOA DE NOSSO ORDENAMENTO JURIDICO, CONSISTINDO, INCLUSIVE, EM PROVA ILÍCITA que macula as demais provas dela derivadas! O acusado exerceu seu direito constitucional ao silêncio em sede inquisitorial e negou formalmente em Juízo, e a única testemunha de acusação que se recordou dos fatos nada trouxe diversamente da confissão informal. Diante desse quadro, ressalta aos olhos a dúvida sobre a autoria delitiva. A dúvida – gerada pela manifesta debilidade instrutória – há que ser interpretada sempre em favor dos acusados. Sem embargo, nenhuma testemunha estranha aos quadros policiais foi convocada para acompanhar o ato (muito embora a abordagem tenha ocorrido na via pública, em contexto que permitia tal providência), o que coloca em ainda maior relevo a ideia de que os testemunhos dos policiais devem ser considerados com cautela. Frágil, pois, a prova carreada ao caderno processual, a recomendar o pronunciamento do non liquet. Caso superada a tese absolutória, a defesa passa a tecer suas postulações subsidiárias. Caso não acolhido o pleito desclassificatório, e sendo necessário infligir penas, a defesa roga sejam elas estipuladas na base mínima, porque favoráveis as circunstâncias judiciais. Em terceira etapa da dosimetria, de rigor a redução das penas, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei Federal nº 11.343/06 (Apelação Criminal n. 998.213-3/7 – São Paulo – 14ª Câmara do 7º Grupo da Seção Criminal – Relator: Alfredo Fanucchi – 15.03.07 – V.U. – Voto n.

4.643). De saída, fixada a pena segregativa em patamar igual ou inferior a quatro anos de reclusão, possível a aplicação do disposto no art. 44, do Código Penal, com a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Aguarda-se, na esteira do acima exposto, permita-se ao acusado – por óbvio, desde que fixadas penas iguais ou inferiores a quatro anos –, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Por fim, pugna pela fixação do

regime mais favorável à hipótese (aberto), guardando proporcionalidade à substituição pretendida. Também neste passo é preciso destacar que não se ignora que o artigo 2º, §1º, da Lei 8.072/90, estipula que o regime inicial para desconto da pena segregativa nos crimes hediondos e assemelhados é o fechado. Entretanto, o que aqui se sustenta é que também este dispositivo está a violar o constitucional princípio da individualização das penas (artigo 5º, XLVI, CF/88), bem como o princípio da proporcionalidade. Evidente, pois, a possibilidade do estabelecimento de regime menos gravoso, o que fica aqui requerido. Em suma, requer: A) a absolvição do acionado, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; B) na remota hipótese de improvimento do pedido absolutório, b.1) seja a conduta desclassificada para a infração prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06; b.2) sejam estabelecidas penas-base no patamar mínimo legal; b.3) caso não acolhido o pleito b.1, seja aplicada, em terceira fase da dosimetria da reprimenda, a causa de diminuição de penas prevista no art. 33, § 4º, da Lei Federal nº 11.343/06, em sua máxima fração (2/3); b.4) fixada a pena privativa de liberdade em patamar igual ou inferior a quatro anos de reclusão, haja a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, reconhecendo-se validade à Resolução nº 5/12, do Senado Federal, e declarando-se, por conseguinte, a inconstitucionalidade da parte intermediária do §4º ao artigo 33, da Lei nº 11.343/06 ('...vedada a conversão em penas restritivas de direitos...'), b.5) haja a fixação do regime aberto para eventual cumprimento da reprimenda segregativa, providência que tem como pressuposto lógico a declaração da inconstitucionalidade também do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com sua redação dada pela Lei nº 11.464/07 ('A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado.'), e guarda proporcionalidade com a substituição pretendida, o que fica aqui requerido. Requeiro seja permitido recorrer em liberdade, eis que ausentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar. Pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. RAFAEL DOS SANTOS SILVA DE SOUSA, qualificado nos autos, está sendo processado porque, conforme narra a denúncia, na data, horário e local nela descritos, , trazia consigo, para entrega e comercialização a terceiras pessoas, drogas, consistentes em 5,3g (cinco gramas e três decigramas) de cocaína, divididos em 77 (setenta e sete) invólucros plásticos, 12,4g (doze gramas e quatro decigramas) de Tetrahidrocannabinol (THC), popularmente conhecido como maconha, divididos em 18 (dezoito) invólucros plásticos, 46,2g (quarenta e seis gramas e dois decigramas) de cocaína, divididos em 74 (setenta e quatro) invólucros plásticos, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com disposição legal ou regulamentar. O réu foi preso em flagrante, sendo após livrado solto. Notificado, houve defesa preliminar, devidamente apreciada. Recebida a denúncia, foi o réu citado e na instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia. O réu foi interrogado. Em razões finais, pugnou o Ministério Público pela condenação do imputado, nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pediu a absolvição por insuficiência de provas, além das teses e dos benefícios requeridos nesse termo. É o relatório. Decido. A ação penal transcorreu sem que houvesse qualquer mácula processual. O feito está em termos para a sentença. A materialidade do delito de tráfico de drogas restou bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo químico-toxicológico positivo para maconha e cocaína, além da prova oral colhida. A autoria, outrossim, está demonstrada, pelo que consta do conjunto probatório, a indicar que as substâncias entorpecentes eram trazidas pelo réu, para fins de comércio. Em seu interrogatório judicial, o réu negou o narcotráfico e disse que não tinha droga consigo. Anotou que a polícia encontrou a droga no chão, largada pelo indivíduo que correu, o qual não conhecia. Na polícia, calou-se, não desejando defender-se desde logo, em conduta, in casu, sintomática de responsabilidade. A denúncia procede. A testemunha Lucas viu o réu e outro indivíduo no local dos fatos e ambos correram. O réu foi abordado. Com ele foi encontrada bolsa com as drogas. Disse que toda a droga encontrada foi apreendida, em porções individualizadas, sendo mais de um tipo de entorpecente. Anotou que o réu confessou o narcotráfico. Não conhecia o réu antes dos fatos. Não viu ato de venda. Alguém pode ter visto a abordagem mais ao longe. A testemunha Jessan não se

lembrou dos fatos. Disse ele, no entanto, no auto do flagrante, o mesmo que a testemunha Lucas confirmou em juízo, dizendo que o réu correu com outros indivíduos, mas foi abordado, sendo encontrado com as drogas indicadas na denúncia, além de dinheiro, acabando por confessar a prática do narcotráfico. A condenação é de rigor, diante do conjunto probatório suficiente, a indicar que o réu trazia drogas para o comércio ilícito. As testemunhas ouvidas, outrossim, não são suspeitas, mormente apenas por serem agentes da segurança pública. Nada há que as impeça de depor e de se crer em suas palavras, ainda mais quando roboradas pelo restante do conjunto de provas. Em juízo houve testemunha ratificando com firmeza a prova acusatória. Não haveria motivo para as testemunhas, que sequer conheciam o réu, o acusarem falsamente, intrujando drogas. O fato de terem corrido mais uma ou duas pessoas com o réu não fragiliza a prova. Tem-se que correu com mais alguém e foi abordado e detido na posse das drogas, em porções prontas para a venda, confessando o narcotráfico. Na essência, a prova é mesmo desfavorável e suficiente para a responsabilização do réu. A redução da sanção, indicada no § 4º, do artigo 33 da lei nº 11.343/06, que dispõe que as penas referentes a este artigo poderão sofrer redução de um sexto a dois terços, caso seja o agente primário, de bons antecedentes, e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, deve ser aplicada, posto ser o caso do ora imputado. A redução deve se dar no patamar de próximo ao máximo de lei, de três quintos, pois a quantidade de drogas é pequena, mormente no que toca ao peso, cerca de sessenta gramas. Afasto, em razão da prova colhida, a desclassificação para porte de droga para uso pessoal. Na fixação da pena do tráfico de drogas, atento às circunstâncias do caso em tela, e ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, deve a sanção ser fixada no mínimo legal, perfazendo pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. Na segunda fase, compenso o aumento da sanção de três meses, em virtude do crime praticado em pleno período de declaração de calamidade pública, com a atenuante da menoridade relativa, restando a pena inalterada. Por fim, reduzo a sanção do patamar já indicado, três quintos, em razão da primariedade, com pena final de dois anos de reclusão e duzentos dias multa. Ante o exposto e o que mais consta dos autos, Julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR, como CONDENO, o réu RAFAEL DOS SANTOS SILVA DE SOUSA, qualificados nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, a cumprir as penas de 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias multa no valor unitário mínimo legal. Diante do cancelamento da súmula 512 pelo E. STJ, em consonância com decisão plenária do E. STF, que julgou ausente o caráter de hediondez do delito do tráfico chamado privilegiado, quando o §4º do artigo 33 é aplicado, resta no caso presente afastado o caráter de hediondez do delito. Outrossim, em cumprimento à decisão em HC (596.603-SP), com abrangência de coletivo, proferida pelo E. STJ, vedada a imposição de regime fechado (ainda que inicial) a casos como o presente, de tráfico privilegiado, em que se aplicou o §4º do artigo 33, da Lei Antidrogas, e dessa forma afastado eventual entendimento do juízo por regime prisional inicial mais severo, imponho o regime aberto para o início do cumprimento de pena, desde logo, mais uma vez atento ao referido HC coletivo, eis que em tal r. decisão consta a determinação de imposição de regime aberto em casos como o presente, em que a pena mínima ou próxima do mínimo, com a redução máxima ou próxima do máximo, foi imposta. Por tal motivo, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consubstanciadas na prestação de serviços à comunidade e na prestação pecuniária que fixo em um salário mínimo, dirigido a instituição com destinação social, a critério do MM. Juízo das Execuções Criminais. Poderá apelar em liberdade. Autorizo a incineração da droga, se já não feita. Declaro o perdimento do dinheiro apreendido com a droga, porque ligado de algum modo ao tráfico de drogas, pelo que noticia a prova dos autos, remetendo-se o montante ao Funad. Transitada em julgado, resta o réu ciente de que deverá recolher pena de multa em dez dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. Custas pelo Estado. Dou a sentença por publicada em audiência. Em razão de, no momento da publicação, terem já o MP e a Defesa técnica, bem como o réu, se retirado do ambiente virtual, intimem-se as partes acerca da sentença, bem como o réu. Registre-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Nada Mais. Eu, André

Paiva Macedo, escrevente, digitei.

O Meritíssimo Juiz de Direito MARCELLO OVÍDIO LOPES GUIMARÃES